

1500150-18.2022.8.26.0621
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: LUIZ HENRIQUE ANTICO
Comarca: Roseira
Foro: Foro de Roseira
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 05/08/2022
... meses de reclusão.

"TÓXICOS - Tráfico - Reconhecimento com base na quantidade e variedade de entorpecente, bem como a forma de acondicionamento - Cabimento - Prisão do agente em pleno ato de comércio - Desnecessidade - Recurso parcialmente provido. PENA - Fixação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Crime praticado a cerca de 300 metros de distância da escola mais ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Roseira
Foro de Roseira
Vara Única
Rua Dom Epaminondas, 54, Roseira-SP - cep 12580-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500150-18.2022.8.26.0621 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500150-18.2022.8.26.0621
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2048835/2022 - Delegacia de Polícia de Roseira, 23134799 - Delegacia de Polícia de Roseira, 401/22/201 - Delegacia de Polícia de Roseira, 2048835 - DEL.POL.ROSEIRA, 401/22/201 - DEL.POL.ROSEIRA
Autor:
Justiça Pública
Indiciado:
CLODOALDO JOSE DA SILVA JUNIOR
Réu Preso

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ HENRIQUE ANTICO

V I S T O S.

Trata-se de Ação Penal Pública Incondicionada através da qual a Justiça Pública local atribui a CLODOALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR, qualificado nos autos, suposta transgressão ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06. Segundo o descrito pela acusação, no dia 19 de fevereiro de 2022, por volta das 21h59min, na via pública, nas proximidades da Rua Professor Calmon, nº 47, centro, nesta cidade, o acusado trazia consigo, com finalidade de entrega a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 27 microtubos, tipo eppendorf, contendo cocaína, pesando aproximadamente 24,53g, 03 porções de cocaína, na forma

sólida (pedra), também conhecida como “crack”, pesando aproximadamente 6,56g, e 01 porção de substância vulgarmente conhecida como “maconha”, pesando aproximadamente 7,76g, capazes de causar dependência física e psíquica, conforme laudo pericial. É da narrativa da denúncia que no dia dos fatos, de posse dessas substância, o acusado andava pela local dos fatos, momento em que, ao perceber a aproximação da viatura policial, abandonou uma sacola plástica e tentou empreender fuga. Em buscas pelo local a polícia localizou os entorpecentes acima descritos. Conclui a acusação dizendo que as circunstâncias, a quantidade e a diversidade do entorpecente, bem como a forma em que estavam acondicionados, tornam clara a finalidade de comercializar os entorpecentes.

Durante a audiência de Custódia a prisão em flagrante do acusado foi convertida em preventiva - fls. 91.

Em cumprimento ao disposto no artigo 55 da Lei nº 11.343/06 o acusado foi notificado e apresentou a defesa prévia de fls. 175, sem preliminares, exceções ou rol de testemunhas.

Denúncia ministerial acolhida pela decisão de fls. 179.

Seguiu-se o certame destinado à instrução do processo com a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação, bem como interrogatório do acusado - fls. 204 a 206 - audiência gravada pelo sistema Teams.

Em sua derradeira manifestação o Ministério Público posicionou-se quanto à procedência integral da ação penal, com a condenação do acusado. Destacou que as provas são suficientes para a condenação do agente pelo crime a ele imputado pela peça inaugural, baseando-se na prova oral colhida e nos depoimentos uníssonos e coesos prestados pelos milicianos, os quais merecem toda credibilidade, além da perícia toxicológica do material apreendido. Ponderou que o réu admitiu parcialmente os fatos. Concluiu aduzindo que o réu é, de fato, o proprietário dos entorpecentes apreendidos e que estava no local para o comércio clandestino. No que tange à pena, sustentou sua fixação acima do mínimo legal, isto em razão da quantidade das drogas, com negativa quanto à redução do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, isto em razão de recente condenação do acusado pelo mesmo crime, na qual obteve o regime carcerário mais brando, voltando a delinquir, apostando na fixação do regime mais severo - fls. 217.

A defesa do acusado manifestou-se à fls. 237. Pugna pela absolvição do réu, diante da ausência de provas que o incriminem, considerando que não estava no local com a finalidade de tráfico. Asseverou que a prova coletada é insuficiente para a condenação, notadamente pela circunstância de um dos policiais não ter sequer se recordado dos fatos. Como a dúvida nunca fora afastada, a absolvição seria medida de rigor, batendo na tecla de que o réu jamais admitira a traficância no local.

É o breve apanhado do processo.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Submetidas as substâncias apreendidas ao denominado Exame Químico Toxicológico (fls. 186), constatou-se que, de fato, cuida-se de “cocaína” e “maconha”. A perícia levada a efeito não deixa margem a dúvida do atributo psicotrópico do entorpecente apreendido, capaz de causar dependência psíquica, incluída, portanto, na Lista de Substâncias de Uso Proscrito no Brasil, constante da Portaria SVS/MS nº 344, de 12/05/98, republicada no Diário Oficial da União de 01/02/99 e a RDC nº 03, da Agência de Vigilância Sanitária, datada de 08/01/04. Comprovou-se, assim, a materialidade do delito, satisfazendo a exigência contida no artigo 158 do Código de Processo Penal, na medida em que a infração penal apurada nos autos é daquela que deixa vestígios (“delicta facti permanentis”), contando, ainda, com o reforço

do auto de exibição e apreensão de fls. 39 e auto de constatação provisória de fls. 57.

Se o tema relativo à apreensão da droga e seus efeitos psicotrópicos não oferece maior resistência, inversa é a situação no que toca à autoria do acusado.

Apesar dos argumentos apresentados pelo ilustre defensor, a inocência do acusado não há de ser proclamada por este juízo, notadamente pela falta de prova de vinculação do agente com as drogas.

A prova colhida ao longo da persecução penal é incriminadora e não deixa vestígio algum de dúvida que possa resultar na aclamada absolvição do increpado, nada obstante a negativa do réu em pretório.

O Policial Militar ouvido em audiência, FÁBIO HENRIQUE OLIVEIRA, fls. 205, narrou de forma detalhada como teria se dado a ação que flagrou o agente na posse dos entorpecentes apreendidos. Disse que já avistou o acusado em atitude suspeita caminhando pela rua. Assim que percebeu a presença policial, o réu dispensou algo no chão e tentou se evadir do local, mas acabou sendo contido. Em buscas realizadas no local em que teriam visto o réu arremessar o objeto localizaram um saco plástico contendo as substâncias entorpecentes que foram apreendidas.

Nem de longe há que se desconfiar dos relatos do policial. Nunca se comprovou nada de efetivo no sentido de que os policiais tivessem algum motivo para incriminar o acusado, que sequer alegou qualquer suposta perseguição.

Note-se, a propósito, que o outro policial ouvido, ADRIANO BARBOSA DE SOUZA (fls. 204), pouco soube informar a respeito dos fatos, não se lembrando de detalhes da ocorrência, circunstância que empresta maior credibilidade à versão de seu parceiro, deixando evidente ambos não tinham intenção de incriminar falsamente o réu.

Assim, opostamente ao que parece ser a crença da defesa, a falta de memória do policial quanto aos fatos não fragiliza a prova acusatória, antes lhe empresta ainda maior vigor, por revelar que inexistente entre os policiais qualquer lição decorada, destinada a incriminar um possível inocente.

Em se tratando de depoimento de policiais, estes são admissíveis e mesmo sendo a única prova em desfavor do acusado servem de suporte ao decreto condenatório, gozando de presunção de veracidade, somente vencível por meio de prova inconteste em contrário.

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta da suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador” (RT 616/286).

“Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta da suspeição” (RT 614/275).

A vetusta e ultrapassada tese que se formou de que a prova fincada exclusivamente no depoimento policial não pode ser admitida e há muito não vem sendo acolhida, pois seria extremamente paradoxal o Estado credenciar seus agentes para a nobre

missão de combate à criminalidade e ao mesmo tempo não emprestar crédito a esses policiais.

A prova contida nos autos, inversamente do sustentado pelo combativo defensor, não é dada frágil. Muito pelo contrário, mostra-se firme, coesa e robusta o suficiente para formar a convicção de que o acusado participava ativamente do tráfico de drogas que grassa na cidade e estava no local usualmente frequentado para essa finalidade. Aliás, não se pode perder de vista que o réu era recém-egresso do sistema carcerário, justamente por ter sido condenado pelo mesmo crime - fls. 73. O réu fora posto em liberdade em 01/12/21, tendo sido preso novamente em 19/02/22, portanto, pouco mais de dois meses de ganhar a liberdade.

A própria negativa por parte do acusado, contrariando a firme versão policial, no sentido de que não dispensara qualquer entorpecente, já é prova de que a quantidade era mais do que suficiente para configurar a traficância, pois do contrário teria assumido a posse das drogas. No mais, como visto, o réu admitiu a posse de parte das drogas, justamente daquela de menor quantidade, certamente por ter conhecimento das consequências de sua conduta.

O ônus da prova, segundo regra do artigo 156 do Código de Processo Penal, cabe a quem o alega, no caso específico ao imputado, o qual não obteve sucesso na demonstração de que os policiais o perseguiram ou estariam mentindo a respeito da apreensão das drogas em seu poder. Lembre-se que os milicianos sequer são policiais de Roseira e nem conheciam o réu.

"Ônus da prova (ônus probandi) é a faculdade que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse. Dispõe a lei que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, princípio que decorre inclusive da paridade de tratamento das partes" (Júlio Fabbrini Mirabete - Código de Processo Penal Interpretado - pg. 220).

"Quem invoca um alibi, para ser absolvido, carece de cumpridamente demonstrá-lo, não bastando, para tal fim, produção de elementos de convicção que não excluam de vez a possibilidade de ter sido o autor da infração" (Ap. 53.726 - TACRIMSP).

"Iterativa a jurisprudência no sentido de que, quem apresenta um alibi, deve comprová-lo satisfatoriamente, sob pena de ser tido como réu confesso" (Rev. 37.688 - TACRIMSP).

Por outra senda, não socorre eventual argumento de que inexistem provas de que pretendia comercializar a droga apreendida. A forma como estavam separadas as drogas, a quantidade e variedade - cocaína, "crack" e "maconha", somando-se ao silêncio do réu em solo extrajudicial, trazem a certeza da destinação mercantil ilícita.

"Tóxicos - Traficância - 7,24 g de cocaína e 7,03 g de maconha não constituem pequena quantidade, porque permitem, respectivamente, 144 e 145 "carreirinhas" (RJTJRS 159/192).

"Considerados a quantidade (15g) e o valor da cocaína apreendida, em contraste com a modestíssima renda do recorrente confirmam a decisão de primeiro grau, que entendeu configurado o delito capitulado no art. 12 da Lei nº 6.368/76" (RJTJRS 145/115).

"Posse de quantidade muito grande de maconha, ou seja, 780 g, de valor bem superior aos dos ganhos de um mês de trabalho do réu, desenganadamente convence de que a erva se destinava à comercialização e não ao uso próprio do interessado" (JUTACRIM 58/25).

Por tudo isso, impossível não dar amparo à pretensão ministerial.

Desse modo, devidamente marcada a responsabilidade criminal do acusado, passo a individualizar sua pena, obedecendo ao critério trifásico previsto pelo artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias judiciais definidas no artigo 59 do Código Penal são favoráveis ao acusado. A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime foram normais. A condenação anterior pelo mesmo crime não havia transitado em julgado, não servindo sequer para afetar seus antecedentes. A pena, todavia, deve ser majorada, considerando a significativa quantidade e, sobretudo, a variedade de drogas apreendidas, parte delas em forma de pedra de "crack", de alta letalidade e poder viciante. É que o artigo 42 da Lei nº 11.343/06 estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. Desse modo, o aumento deve ser de 1/6, totalizando cinco (05) anos e dez (10) meses de reclusão.

"TÓXICOS - Tráfico - Reconhecimento com base na quantidade e variedade de entorpecente, bem como a forma de acondicionamento - Cabimento - Prisão do agente em pleno ato de comércio - Desnecessidade - Recurso parcialmente provido. PENA - Fixação - Tráfico ilícito de entorpecentes - Crime praticado a cerca de 300 metros de distância da escola mais próxima - Aplicação da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei Federal nº 11343/06 - Descabimento - Local que se situa "em ponto estratégico, entre duas escolas" - Irrelevância, uma vez que a lei se refere a "imediações" - Recurso parcialmente provido para reduzir a pena do apelante" (TJSP - Ap. nº 990.09.281.993-3 - São Paulo - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. Francisco José Galvão Bruno - J. 18.03.2010 - v.u)., sendo que a quantidade de entorpecentes apreendida insuficiente para a exasperação da pena-base, na forma do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, fixando-a em cinco (05) anos de reclusão.

Não existem circunstâncias atenuantes em prol do acusado, bem como agravantes genéricas a serem consideradas. O réu nunca confessou a autoria do crime e o fato de ter admitido a posse de apenas parte dos entorpecentes está longe de configurar confissão, que exige arrependimento.

"A confissão só pode ser reconhecida como atenuante obrigatória quando se dá de forma completa, a fim de se prestigiar a sinceridade do infrator; pois, em hipótese contrária, inexiste verdade total da dinâmica da ocorrência penal" (RJDACRIM 31/84).

"Em se tratando da atenuante da confissão, o agente que, buscando minimizar sua conduta, compromete a verdade processual, não pode reclamar a obtenção do favor legal, pois além do requisito da espontaneidade, não se admite, para efeito de atenuação de penas, confissão pela metade" (Apelação nº 1.027.851/5, Julgado em 12/09/1.996, 7ª Câmara, Relator: - Nogueira Filho, RJTACRIM 33/56).

O artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 traz causa especial de redução de pena ao dispor que nos delitos definidos no "caput" e no parágrafo primeiro deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. As circunstâncias judiciais, conforme já dito, são favoráveis ao acusado, pois é primário e detém bons antecedentes, contudo, é imperioso concluir que se dedique a atividades criminosas, na medida em que não provou ao longo da instrução criminal ter emprego lícito, sendo inegável que o tráfico, delito equiparado aos hediondos, constitui-se em evidente atividade criminosa. Mais que

isso, conforme já apontado, o réu foi preso recentemente e condenado por idêntico delito, tendo cometido o crime pouco mais de dois meses depois de ter obtido a liberdade. Isso revela inegável dedicação à atividade criminosa por parte do acusado que, por sua vez, não comprovou ao longo da tramitação do processo o exercício de atividade lícita.

Além disso, para se beneficiar da causa especial de redução de pena o réu não deve integrar organização criminosa. O delito de tráfico é uma grande engrenagem com inúmeras peças. Vai desde o fabrico da substância entorpecente até o destinatário final que são os consumidores. Até que isso ocorra inúmeras pessoas são envolvidas nessa cadeia criminosa, o que comprova que a apreensão de quantidade elevadíssima de substâncias entorpecentes decorre de organização criminosa que tem toda uma logística, com recrutamento de várias pessoas que atuam em diferentes áreas. O acusado, por certo, era parte integrante dessa organização, ao qual cabia a comercialização das drogas aos usuários desta cidade, por isso mesmo estava perambulando pelas ruas da cidade para a distribuição das drogas. Não existe dúvida alguma de que o réu faz parte desse importante braço da organização, cujo objetivo era a distribuição dos entorpecentes nesta cidade, mantendo aceso o nefasto vício. Irrelevante o fato de o acusado não conhecer os demais integrantes dessa organização, pois também faz parte do sucesso desse tipo de empreitada criminosa a separação entre os diversos componentes da organização. O acusado sabe muito bem que para que a droga chegue até ele tem que passar por outros integrantes da organização. Por conta disso tudo, não merece a redução da pena.

"HABEAS CORPUS - Penal - Tráfico transnacional de drogas - Dosimetria da pena devidamente fundamentada - Aplicação da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 - Impossibilidade - Réu integrante de organização criminosa - Conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito - Ausência de requisito objetivo - Ordem denegada. O indeferimento da causa especial de redução do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 foi devidamente fundamentado, havendo sérios indícios de que o paciente integra organização criminosa ligada ao tráfico internacional de drogas, o que impede a concessão da própria benesse. Ordem denegada" (STF - HC nº 111.398 - SP - 2ª T. - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - J. 17.04.2012 - DJE 03.05.2012).

"Para que a redução da pena prevista no parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/2006 seja concedida, não basta que o agente seja primário e tenha bons antecedentes, sendo necessário, também, que ele não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa. Com base nesse entendimento, a Turma desproveu recurso ordinário em habeas corpus no qual se pleiteava a incidência da referida causa especial de diminuição de pena a condenado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes na vigência da antiga Lei de Tóxicos (Lei 6.368/76, artigo 12). Aduziu-se que, na espécie, a dedicação do recorrente ao tráfico de drogas ficara devidamente comprovada nos autos e que não fora afastada pela defesa na apelação e nas demais impetrações posteriores. Os Ministros Marco Aurélio e Carlos Britto também denegaram o recurso, mas por fundamento diverso, consentâneo com a óptica do tribunal estadual, no sentido de que o aludido parágrafo quarto do artigo 33 da Lei 11.343/2006 não se aplica à situação concreta regida pela Lei 6.368/76, sob pena de se olvidar o critério unitário, chegando ao conglobamento com o surgimento de uma nova regra normativa" (STF - RHC nº 94.802 - RS - Rel. Min. Menezes Direito - J. 10.02.2009).

"TÓXICOS - Tráfico - Afastamento da benesse prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 - Cabimento - Condenados encontrados em atividade criminosa - Quantidade de drogas indicativa de relacionamento estreito dos réus com o crime organizado - Recursos dos réus desprovidos e recurso ministerial provido" (TJSP - Ap. nº 990.10.045.033-6 - Botucatu - 9ª Câmara de Direito Criminal - Rel. José Orestes de Souza Nery - J. 05.08.2010 - v.u).

"PENA - Redução - Prática de tráfico de entorpecentes - Aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 - Inadmissibilidade - Hipótese em que, embora o réu seja primário e não registre maus antecedentes, mostrou comportamento voltado ao delito, não sendo recomendável a adoção dessa medida, que, aliás, é de caráter facultativo, uma vez que a norma legal dispõe que "as penas poderão ser reduzidas", ficando ao prudente arbítrio do Julgador essa análise no caso concreto - Recurso improvido" (Apelação Criminal n. 1.156.870-3/6 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 13.3.2008 - V.U.- Voto n. 7.100).

Por fim, presente a causa especial de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06. Tanto a prova testemunhal como o laudo de fls. 184 comprovam sem dúvida alguma de que o comércio clandestino grassava nas imediações de uma escola, mais precisamente a uma distância de 230 metros da EMEIF Professor Joaquim de Campos.

Para a configuração dessas causas de aumento basta o perigo representado pela conduta praticada em tais circunstâncias, justamente como ocorreu no caso em foco.

O fato de não ter constado da denúncia é de todo irrelevante, considerando que o acusado se defende dos fatos descritos e não da capitulação, não havendo dúvidas de que há perfeita descrição a respeito do local dos fatos na peça acusatória.

Além disso, em se tratando de causa especial de aumento de pena, não há necessidade de sua descrição na denúncia, podendo ser reconhecida de ofício pelo juiz, mesmo porque é de caráter objetivo.

"APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO - Recursos defensivo e ministerial - Pleito de absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas nos autos. Potencialidade lesiva da arma constatada pericialmente. Quantidade de drogas e circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia. Validade dos depoimentos dos policiais - Desclassificação da imputação de tráfico para uso - Descabimento. A condição de mero usuário não exclui, por si só, a prática da mercancia ilícita - Reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas - Acolhimento. Majorante de caráter objetivo, bastando que o delito seja praticado nas proximidades dos estabelecimentos elencados no referido dispositivo legal, o que restou suficientemente comprovado - PENAS - Elevação da sanção do tráfico em 1/6 por força do art. 40, III, da Lei de Drogas - Fixação do regime inicial fechado - Necessidade - Gravidade concreta dos delitos cometidos pelo réu, que determina o cumprimento da pena em regime mais gravoso, bem como desautoriza a concessão de quaisquer benefícios legais - Recurso defensivo desprovido e provimento ao apelo ministerial" (TJSP - Apelação Criminal 0021042-96.2016.8.26.0050; Relator (a): Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/09/2017; Data de Registro: 19/09/2017).

Com efeito, elevo a pena em 1/6, no mínimo por ter sido a infração cometida nas proximidades de apenas um dos estabelecimentos enumerados, totalizando seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão.

Não sendo encontradas outras causas, especiais ou gerais, de aumento ou diminuição de pena, torno a fixada em definitiva.

A multa prevista de forma cumulativa deve ser fixada dentro dos mesmos critérios para o encontro da pena-base. No tocante ao valor, deve-se ter em mira o conteúdo do artigo 43, "caput", da Lei nº 11.343/06, sempre no mínimo legal frente à situação econômica nada privilegiada do réu, num total de 680 dias-multa.

O cumprimento da pena deve ser feito inicialmente no regime FECHADO, considerando a

redação do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, modificada pela Lei nº 11.464/07. Qualquer outra modalidade de regime de cumprimento de pena seria insuficiente para atender às finalidades da pena, ou seja, a repressão e prevenção, principalmente por se tratar de delito equiparado aos hediondos, de singular gravidade. Lembre-se, outra vez, que o réu já fora agraciado com penas mais modestas e o regime de menor intensidade, mas voltou a transgredir a lei penal, prova de que qualquer outra modalidade de regime serviria de verdadeiro estímulo à continuidade delitiva, a exemplo do que ocorreu anteriormente.

“PENA – Regime – Fixação – Tráfico de entorpecentes – Com o advento da Lei nº 11.464/07, o regime de cumprimento de pena não pode mais ser o integralmente fechado, modalidade assinada somente para a fase inicial de cumprimento – Recurso provido” (Apelação Criminal nº 1.039.230-3/2 – Catanduva – 8ª Câmara do 4º Grupo da Seção Criminal – Relator: Lourival Barbiero – 11.9.07 – V.U. – Voto nº 2.439).

“TÓXICOS – Regime prisional – Tráfico – Fixação da modalidade inicial fechada – Necessidade, nos termos da Lei n. 11.464/07 – Regime integral fechado – Descabimento – Recurso parcialmente provido para estabelecer o regime prisional inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade” (Apelação Criminal n. 1.060.484.3/0 – Santos – 9ª Câmara Criminal – Relator: René Nunes – 26.09.07 – V.U. – Voto n. 10.932).

“Tem-se definido a pena como uma sanção aflitiva imposta pelo Estado, por meio da ação penal, ao autor de uma infração, como retribuição de seu ato ilícito, consistente na diminuição de um bem jurídico; seu fim é evitar novos delitos. Tem ela esta função preventiva geral, com fim intimidativo a todos os destinatários da norma penal, e especial, dirigida ao autor do delito para o impedir de cometer novos crimes e reintegrá-lo socialmente” (Código Penal Interpretado – pg. 250 – Júlio Fabbrini Mirabete).

A regra contida no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal não altera o regime carcerário levando-se em consideração o tempo de prisão preventiva do acusado, pois ainda não cumpriu tempo suficiente da pena para obtenção de progressão de regime (artigo 112 e incisos da Lei de Execução Penal). Além disso, o artigo 112, “caput”, e § 1º, da Lei de Execução Penal exigem, além do requisito objetivo para a progressão (tempo de cumprimento da pena), bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão, informações estas que não constam dos autos, impedindo, portanto, a fixação do regime menos severo.

“(…) No que diz respeito à pretendida aplicação da Lei n.º 12.736, tal pleito não pode ser atendido, pois a colenda Turma julgadora não possui elementos para fazê-lo, eis que não há informações a respeito do cumprimento da pena (…)” (TJ/SP, 16ª Câmara Criminal, Apelação n.º 0016604-05.2011.8.26.0114, Rel. Des. Alberto Mariz de Oliveira, j. em 04.06.2013).

“Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento. O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou

não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença" (Relator(a): Grassi Neto; Comarca: Mogi-Guaçu; Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 11/08/2016; Data de registro: 16/08/2016).

Pela ausência de pressuposto objetivo (quantidade da pena) e a hediondez do crime é negado ao réu o benefício do "SURSIS" (artigo 77, "caput", do Código Penal).

Também não merece ser agraciado com nenhuma das penas alternativas previstas pelo artigo 43 do Código Penal introduzido pela Lei nº 9.714/98, pois não preenche o requisito objetivo da quantidade da pena. Além disso, esse tipo de substituição deve ser reservada a crimes de pequena gravidade e é incompatível com o tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, crime de acentuada gravidade e até mesmo equiparado aos hediondos, exigindo por parte do julgador tratamento mais severo, como forma de frear essa atividade, que de tão lucrativa que é a cada dia recruta mais integrantes. Somente com penas severas, efetivamente cumpridas, que esse tipo de delito pode ser contido. Conceder a traficantes a substituição em questão, com a devida vênia dos que pensam diferente, é estimular o tráfico. O argumento de que o julgador deve diferenciar o pequeno do grande traficante mostra-se irrelevante. O tráfico de drogas é mecanismo de grande porte e, como toda engrenagem, depende das pequenas peças para seu perfeito funcionamento. Sem o pequeno traficante não há como difundir o uso das drogas, de sorte que este é fundamental para o sucesso desse mercado clandestino. No mais, comumente quem vicia nossos jovens e vende drogas na porta das escolas são os chamados "pequenos traficantes". Reforce-se que o réu fora pilhado a poucos metros de uma escola.

"TÓXICO - Tráfico - Pena restritiva de direitos - Lei n. 9.714/98 - Aplicação - Inadmissibilidade - Lei de drogas e de crimes hediondos que não admitem a concessão de benefícios - Vedação, ademais, pelo artigo 44, I, do Código Penal - Recurso não provido" (Apelação Criminal n. 289.157-3 - São Paulo - 1ª Câmara Criminal - Relator: Oliveira Passos - 18.01.2000 - V.U.).

"PENA - Restritiva de direitos - Tráfico de entorpecentes - Substituição da privativa de liberdade - Impossibilidade - Obediência ao artigo 44 e seguintes do Código Penal, com a nova redação dada pela Lei nº 9.714/98 - Necessidade - Reconhecimento da especialidade da lei de drogas e da Lei nº 8.072/90 - Hipótese - Recurso improvido" (Apelação nº 934.955-3/4 - Pederneiras - 11ª Câmara Criminal - Relator: Antonio Manssur - 2.8.06 - V.U. - Voto nº 11.274).

"PENA - Reclusão - Tráfico de drogas - Substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos - Impossibilidade - Incompatibilidade com a condição de traficante (artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) - Existência - Recurso não provido neste aspecto" (Apelação Criminal nº 1.180.451-3/5 - Taubaté - 5ª Câmara da Seção Criminal - Relator: Marcos Zanuzzi - 24.4.08 - V.U. - Voto nº 15.940).

Veda-se ao réu o apelo em liberdade. Primeiro porque que aguardou o desfecho da instrução segregado, sendo que agora, depois de condenado, a soltura seria verdadeiro paradoxo. Segundo porque o singelo fato de ser primário não pode autorizar esse tipo de benefício, que deve ser reservado apenas aos crimes de menor gravidade e que não provoquem alarma social, ao contrário do que ocorre com o tráfico de entorpecentes, delito equiparado aos hediondos e de gravidade singular. A libertação do inculcado serviria de estímulo à criminalidade e não se prestaria a colocar freio na vertiginosa onda de crimes que assola e atemoriza nossa sociedade, principalmente o tráfico de drogas, que tem destruído inúmeras famílias. Além disso, conforme já sublinhado, os pressupostos e fundamentos que autorizam a prisão

preventiva estão presentes, havendo efetivo risco para a aplicação da lei penal, notadamente em virtude da condenação e da pena elevada imposta ao agente. As demais medidas cautelares previstas pelo artigo 319 e incisos do Código de Processo Penal não são suficientes à gravidade do delito e, em especial, à condição pessoal do acusado, conforme exigido pelo artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal. Observo que o crime imputado ao agente tem pena máxima que ultrapassa a quatro anos de prisão, permitindo, portanto, a custódia cautelar (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal). A gravidade do delito é concreta e a libertação do acusado, principalmente nesta fase do processo, com pena aplicada, soaria a todos, inclusive a ele, como impunidade. No mais, ficam reiterados os argumentos empregados por ocasião da r. decisão que converteu a prisão em flagrante do acusado em preventiva, pois perfeitamente válidos ao caso, assim como aqueles manejados na decisão de fls. 164, nunca perdendo de foco que o agente recebeu o benefício da liberdade provisória e meses depois tornou a ser preso pelo mesmo crime.

"CONSTRANGIMENTO ILEGAL - Tráfico de entorpecente - Condenação - Regime inicial fechado - Crime Hediondo - Negado o apelo em liberdade - Legalidade - Não caracterização - Perniciosidade do tráfico que justifica a continuidade da segregação - Ordem denegada" (Habeas Corpus n.º 247.004-3 - São Paulo - 3ª Câmara Criminal de Férias de Janeiro/98 - Relator: Segurado Braz - 14.01.98 - V.U.).

"HABEAS CORPUS - Réu preso em flagrante e condenado por prática de crime hediondo, tráfico de entorpecentes, que recorreu da sentença e que pretende liberdade provisória para aguardar o resultado do julgamento - Alegação de que necessita de tratamento médico - Irrelevância - Obrigação do Estado de fornecer o aludido tratamento - Artigo 35 da Lei 6.368 de 1976, que manteve a permanência na prisão como condição do apelo - Ordem denegada" (Habeas Corpus n.º 259.177-3 - Barretos - 6ª Câmara "JULHO/98" de Direito Público - Relator: Debatin Cardoso - 22.07.98 - V.U.).

"Para a garantia da ordem pública, visará o magistrado, ao decretar a prisão preventiva, evitar que o delinquente volte a cometer delitos, ou porque é acentuadamente propenso às práticas delituosas, ou porque, em liberdade, encontraria os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida" (JTACRESP 42/58).

"A garantia da ordem pública, dada como fundamento da decretação da custódia cautelar, deve ser de tal ordem que a liberdade do réu possa causar perturbações de monta, que a sociedade venha a se sentir desprovida de garantias para a sua tranquilidade" (RDJTACRIM 11/201).

Importante deixar assentado que a negativa quanto ao direito de apelar em liberdade não está fundada na regra do artigo 44 da Lei nº 11.343/06, cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC 104.339-SP, mas na existência de pressupostos e fundamentos que autorizam a prisão preventiva, conforme acima registrado e que também foram levados em consideração quando da audiência de custódia, bem em outras decisões deste juízo.

"À luz da nova ordem constitucional, que consagra no capítulo das garantias individuais o princípio da presunção da inocência (CF/88, artigo 5º, LVII), a faculdade de recorrer em liberdade objetivando a reforma de sentença penal condenatória é a regra, somente impondo-se o recolhimento provisório do réu à prisão nas hipóteses em que enseja a prisão preventiva, na forma inscrita no artigo 312, do CPP. Na hipótese em que o réu foi considerado reincidente e permaneceu foragido durante todo o curso do processo, não é cabível o benefício de apelar em liberdade. "Habeas corpus" denegado" (STJ - HC nº 7.272 - SP - Rel. Min. Vicente Leal - J. 25.08.98 - DJU 28.09.98).

“Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a custódia cautelar do paciente, se demonstrada a necessidade da prisão, atendendo-se aos termos do art. 312 do CPP e da jurisprudência dominante. A evasão do réu pode ser suficiente para motivar a segregação provisória a fim de garantir a aplicação da lei penal. Precedente. Não se conhece de pedido de extensão da decisão do e. Tribunal a quo, que revogou a prisão cautelar de co-réu, pois o mesmo deveria ter sido dirigido à Autoridade que concedeu a ordem, competente para tanto. Recurso parcialmente conhecido e desprovido” (STJ - RHC nº 12.236 - PR - 5ª T. - Rel. Min. Gilson Dipp - DJU 25.03.2002).

Ante ao exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a Ação Penal, CONDENANDO o acusado CLODOALDO JOSÉ DA SILVA JÚNIOR (R.G. nº 62.078.593), por ter infringido o disposto no artigo 33, “caput”, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de seis (06) anos, nove (09) meses e vinte (20) dias de reclusão (REGIME FECHADO) e pagamento de seiscentos e oitenta (680) dias-multa, no valor de um trinta avos do maior salário mínimo vigente à época dos fatos (salário mínimo paulista), na forma prevista pelo artigo 43 da Lei nº 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no livro destinado ao rol dos culpados, oficiando-se para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Recomende-se o réu na prisão em que estiver recolhido.

P.I.C.

LUIZ HENRIQUE ANTICO
Juiz de Direito

Roseira, 05 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA